Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Fonti, direttive e Costituzione

Punto 1 del programma — evoluzione della legislazione bancaria e Costituzione economica

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
13 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Fonti, direttive e Costituzione **1**

1.1 D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario 1
1.2 D2 — Art. 47 Cost.: la tutela del risparmio e la disciplina del credito 1
1.3 D3 — Art. 41 Cost. e il legame con l'art. 47 2
1.4 D4 — Art. 117 Cost.: chi legifera in materia bancaria 2
1.5 D5 — La prima direttiva banche: che cosa resta oggi 3
1.6 D6 — La seconda direttiva: i principi valgono ancora oggi? 3
1.7 D7 — Vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale 4
1.8 D8 — La despecializzazione: istituzionale, operativa e temporale 4
1.9 D9 — Il residuo di specializzazione oggi: BCC e popolari 5
1.10 D10 — L'art. 1 e la banca come «impresa autorizzata» 5
1.11 D11 — La banca come impresa: in che cosa è derogato lo statuto dell'imprenditore 6
1.12 D12 — La riserva dell'attività bancaria, la raccolta tra il pubblico e la riserva di denominazione 6
1.13 D13 — Il TUB e il Testo unico della finanza 7

1 | Fonti, direttive e Costituzione

Questo capitolo copre il punto 1: la Costituzione economica (artt. 41, 47 e 117), le prime due direttive e ciò che ne resta oggi, la despecializzazione, la banca come impresa autorizzata e la riserva dell'attività bancaria. Urbani entra nel dettaglio sui tre articoli costituzionali e sul legame fra 41 e 47; con gli assistenti direttive e despecializzazione tornano sempre con il taglio «e oggi vale ancora?». La storia si chiede solo per spiegare una norma di oggi, e l'esaminatore cita il numero dell'articolo.

1.1. D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario

Domanda. Prima di entrare nel merito, mi dica di che cosa si occupa la legislazione bancaria e in che cosa si distingue dal diritto bancario.

Risposta ideale. La legislazione bancaria è la disciplina pubblicistica dell'impresa bancaria: stabilisce chi può fare la banca, con quale forma, quale capitale, quali soci ed esponenti e sotto quali controlli. Il diritto bancario riguarda invece l'operatività, cioè i contratti con cui la banca lavora con la clientela. La norma di cerniera è l'art. 10 del Testo unico, che definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, dice che «ha carattere d'impresa» e la riserva alle banche. Ne deriva la natura mista della materia. È privatistica, perché la banca è impresa e vale il diritto commerciale; è pubblicistica, perché la vigilanza è esercitata da autorità pubbliche con provvedimenti, tanto che l'art. 4, comma 3, richiama la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, e perché il Titolo VIII contiene sanzioni anche penali. La stessa duplicità spiega la struttura del TUB, che segue la banca nel suo ciclo di vita: nasce con l'autorizzazione, si organizza, è vigilata, può entrare in crisi. Va poi chiarito che il TUB non è un codice dei contratti bancari: i tipi contrattuali restano nel codice civile, il Titolo VI si occupa di trasparenza e dunque di protezione del cliente, e solo alcune operazioni, come il credito fondiario, hanno una disciplina speciale. Per questo il corso insiste sull'attitudine a consultare le fonti: per ogni istituto bisogna sapere a quale piano appartiene e quale articolo lo regge.

1.2. D2 — Art. 47 Cost.: la tutela del risparmio e la disciplina del credito

Domanda. Mi commenti l'art. 47 della Costituzione e mi dica che cosa ne discende per la legislazione bancaria.

Risposta ideale. L'art. 47 è il fondamento costituzionale della legislazione bancaria: la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Ne discende non solo la legittimità, ma la doverosità di una disciplina del credito, che lo Stato non può lasciare al mercato. L'espressione «in tutte le sue forme» copre sia il risparmio affidato alla banca come deposito sia quello investito in strumenti finanziari, con tecniche diverse: la vigilanza prudenziale per il primo, la trasparenza e le regole di condotta per il secondo. I tre verbi indicano tre funzioni, normativa, di indirizzo e di controllo, che il TUB distribuisce fra le tre autorità creditizie del Titolo I: CICR, Ministro dell'economia e Banca d'Italia. Il ponte con il Testo unico è l'art. 5, che traduce il precetto in finalità della vigilanza: sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni sul credito. Due limiti vanno tenuti fermi. L'art. 47 impone che una disciplina esista, non questa disciplina: il TUB è legge ordinaria e il legislatore può modificarlo. E non costituzionalizza alcuna autorità, perché parla di Repubblica e non di Banca d'Italia. Resta da capire come questo precetto conviva con la libertà d'impresa, cioè con l'art. 41.

1.3. D3 — Art. 41 Cost. e il legame con l'art. 47

Domanda. Commenti l'art. 41 della Costituzione e mi dica che legame ha con l'art. 47: come si concilia la libertà d'impresa con i vincoli pubblicistici che gravano sulla banca?

Risposta ideale. L'art. 41 dice che l'iniziativa economica privata è libera, che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno a salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana, e che la legge determina i programmi e i controlli perché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Poiché per l'art. 10 TUB l'attività bancaria «ha carattere d'impresa», la banca è titolare di questa libertà. Il legame con l'art. 47 non è la prevalenza della norma speciale su quella generale, ma un'integrazione: l'art. 41 consente alla legge di indirizzare l'impresa a fini sociali, e l'art. 47 compie questa scelta per il credito già a livello costituzionale, sicché il bilanciamento non va rifatto caso per caso. Il punto di equilibrio è la proporzionalità: ogni vincolo, dall'autorizzazione dell'art. 14 al controllo sulle partecipazioni dell'art. 19, deve trovare fondamento nelle finalità dell'art. 5, essere idoneo a perseguirle e non comprimere l'autonomia oltre il necessario. E poiché la riserva di legge del terzo comma è relativa, la legge può fissare i criteri e rinviare il dettaglio alla normativa secondaria: per questo la delegificazione del TUB è legittima. Oggi la legge costituzionale 1/2022 ha aggiunto salute e ambiente fra i limiti del comma 2 e i fini ambientali al comma 3, ed è la copertura costituzionale dei poteri sui rischi ambientali, sociali e di governance dell'art. 53-bis, comma 1, lett. d).

1.4. D4 — Art. 117 Cost.: chi legifera in materia bancaria

Domanda. A chi spetta la potestà legislativa in materia bancaria? Mi illustri l'art. 117 e mi dica quale spazio resta alle Regioni.

Risposta ideale. La materia è statale, nel rispetto dei vincoli europei. L'art. 117, comma 2, lett. e), riserva alla legislazione esclusiva dello Stato «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», con la tutela della concorrenza e il sistema valutario: è la voce che copre la disciplina del credito. Vi si affianca la lett. l), ordinamento civile, che consente allo Stato di dettare anche le regole societarie e contrattuali delle banche, comprese quelle che derogano al codice civile. Il comma 1 sottopone Stato e Regioni ai vincoli dell'ordinamento dell'Unione e agli obblighi internazionali: il primato del diritto europeo poggia sull'art. 11 e, dal 2001, anche su questo comma, e il TUB lo riflette nell'art. 6. Alle Regioni resta uno spazio residuale. Il comma 3 elenca fra le materie concorrenti casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, ma è un residuo storico, perché la despecializzazione ha superato quelle categorie. Le tracce regionali stanno nel TUB, che è legge statale. L'art. 159 riserva le valutazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, impone il suo parere vincolante quando un provvedimento spetta a una Regione e, al comma 4-bis, vuole che quelle competenze si esercitino nei limiti del MVU. L'art. 37-bis, comma 1-bis, consente alle BCC di Trento e Bolzano un gruppo provinciale o, in alternativa, un sistema di tutela istituzionale.

1.5. D5 — La prima direttiva banche: che cosa resta oggi

Domanda. La prima direttiva banche, quella del 1977: che cosa ha fatto, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Della prima direttiva resta l'impianto, non la lettera, perché è formalmente abrogata: dalla direttiva 2000/12/CE, art. 67, poi rifusa nella 2006/48/CE e oggi nella CRD IV, art. 163. È la 77/780/CEE, venuta dopo la «direttiva zero» del 1973, che si era limitata a eliminare le restrizioni a stabilimento e libera prestazione di servizi. Fissò una nozione comune di ente creditizio, l'impresa che raccoglie fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto; vietò di esaminare la domanda di autorizzazione in funzione delle «esigenze economiche del mercato», art. 3, par. 3, salvo una deroga transitoria; avviò la collaborazione fra autorità. Senza una nozione comune non c'è nulla da riconoscere reciprocamente. All'Italia creò un problema, perché la legge bancaria del 1936-38 non enunciava i criteri dell'autorizzazione: il recepimento arrivò solo con il d.P.R. 350/1985. E oggi? Il binomio raccolta e credito è nell'art. 10, comma 1, TUB, e il divieto per i non bancari è nell'art. 11, comma 2, come nell'art. 9 della CRD IV. L'autorizzazione poggia sulle condizioni dell'art. 14, comma 1, cioè forma, sede e direzione generale, capitale, programma di attività, partecipanti, esponenti, assenza di stretti legami, e il diniego del comma 2 non guarda al mercato ma alla sana e prudente gestione. Cambia l'autorità: oggi l'autorizzazione è della BCE su proposta della Banca d'Italia.

1.6. D6 — La seconda direttiva: i principi valgono ancora oggi?

Domanda. Mi parli dei principi della seconda direttiva banche. Valgono ancora oggi?

Risposta ideale. I principi valgono ancora, anche se la direttiva è formalmente abrogata: dalla 2000/12/CE, art. 67, poi rifusa nella 2006/48/CE e oggi nella CRD IV, art. 163. La seconda

direttiva, la 89/646/CEE richiamata nel preambolo del TUB, poggiava su mutuo riconoscimento, armonizzazione minima e controllo dello Stato d'origine. Il mutuo riconoscimento è la licenza unica, il passaporto: la banca autorizzata in uno Stato può stabilire succursali o prestare servizi negli altri. Il TUB lo traduce negli artt. 15 e 16 e nell'art. 1, comma 2, lett. f), che elenca le attività riconosciute, dalla raccolta di depositi al leasing, ai servizi di pagamento: è la banca universale. Licenza unica e controllo dello Stato d'origine restano, con l'art. 49 della CRD IV. L'armonizzazione minima è invece superata nella disciplina prudenziale, che sta nel CRR, regolamento direttamente applicabile, e la vigilanza sulle banche significative è della BCE dal 2014. Anche l'eccezione della liquidità è superata: la vigilanza sulle succursali restò allo Stato ospitante solo in via transitoria, art. 156 CRD IV, finché non si applicò il requisito di copertura della liquidità del CRR, art. 151, par. 1. All'ospitante restano le misure cautelative urgenti a tutela di depositanti, investitori e clienti, art. 43, e quelle contro le violazioni delle sue norme di interesse generale, art. 44 CRD e art. 15, comma 3, TUB.

1.7. D7 — Vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale

Domanda. Mi spieghi la differenza fra vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale: perché oggi la vigilanza è prudenziale e dove lo si legge nel TUB?

Risposta ideale. Nella vigilanza strutturale l'autorità conforma il mercato: decide quante banche esistano, con quale specializzazione, in quali territori e con quanti sportelli. È il modello della legge bancaria del 1936-38, coerente con il suo obiettivo: se la concorrenza genera instabilità, la stabilità si ottiene comprimendola, al prezzo di una rendita di posizione. Nella vigilanza prudenziale l'autorità non dice alla banca che cosa fare, ma con quanta prudenza farlo: fissa regole di patrimonio, di rischio e di governo societario, e dentro quei confini l'iniziativa è libera. Nel TUB la scelta si legge in tre luoghi. L'art. 5 mette fra le finalità della vigilanza, accanto alla sana e prudente gestione e alla stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema, e fa quindi della concorrenza un interesse tutelato. L'art. 53, comma 1, affida alla Banca d'Italia le disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario, controlli interni e remunerazioni. Il segno più concreto è l'art. 15: nel mercato interno le banche stabiliscono succursali secondo le procedure del Meccanismo di vigilanza unico, alla Banca d'Italia resta solo il potere di vietare la nuova succursale di un soggetto meno significativo per ragioni organizzative o di situazione finanziaria, e l'autorizzazione sopravvive per le succursali in Stati terzi. È la stessa logica della despecializzazione.

1.8. D8 — La despecializzazione: istituzionale, operativa e temporale

Domanda. Mi spieghi che cosa si intende per despecializzazione e su quali piani opera nel TUB.

Risposta ideale. La despecializzazione è il superamento del sistema del 1936-38, in cui esistevano molte categorie di enti creditizi, ciascuna con il proprio statuto, il proprio orizzonte

temporale e il proprio ambito operativo. Il TUB la realizza su tre piani. Sul piano istituzionale l'art. 14, comma 1, lett. a), riduce le forme possibili a due, società per azioni e società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e scompare la pluralità di casse, istituti di diritto pubblico e istituti di credito speciale. Sul piano temporale non c'è più la distinzione fra aziende di credito, abilitate al breve termine, e istituti di credito speciale, abilitati al medio e lungo: il TUB conosce solo le banche. Il rischio di trasformazione delle scadenze non scompare, ma si governa con regole prudenziali sulla liquidità, oggi nel CRR, e non con la separazione degli enti. Sul piano operativo l'art. 10, comma 3, abilita la banca, oltre all'attività bancaria, a ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna e alle attività connesse o strumentali, salve le riserve di legge: non tutto, dunque, ma ciò che è finanziario e senza invadere riserve altrui. Restano discipline speciali, come il credito fondiario e agrario, ma riguardano l'operazione e non il soggetto. Il residuo di specializzazione soggettiva è invece cooperativo, ed è il passaggio successivo.

1.9. D9 — Il residuo di specializzazione oggi: BCC e popolari

Domanda. Che cosa resta oggi della specializzazione? Le BCC e le popolari sono ancora un'eccezione?

Risposta ideale. Il residuo è la forma cooperativa. L'art. 14, comma 1, lett. a), ammette la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e l'art. 28, comma 1, riserva l'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa alle sole banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Il residuo vero sono le BCC. L'art. 35, comma 1, impone loro di esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci, e la Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, una operatività prevalente a favore di non soci soltanto per ragioni di stabilità; il comma 2 rinvia agli statuti, sulla base dei criteri della Banca d'Italia, per attività, impieghi, raccolta e competenza territoriale. Solo alle BCC, ai fini fiscali, l'art. 28, comma 2-bis, riconosce la mutualità prevalente, e dal 2016 l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis. Le popolari sono un residuo debole. Restano cooperative, con voto capitario e tetti al possesso, ma non sono a mutualità prevalente e hanno un limite di attivo di 16 miliardi: oltre quella soglia devono ridurre l'attivo, trasformarsi in s.p.a. o liquidarsi, secondo l'art. 29, commi 2-bis e 2-ter. Il distinguo è questo: nelle BCC la specialità è di scopo, cioè mutualità prevalente e operatività con i soci; nelle popolari è soltanto di forma, cioè voto capitario e limiti al possesso.

1.10. D10 — L'art. 1 e la banca come «impresa autorizzata»

Domanda. Il TUB si apre con un articolo di definizioni. Che senso ha, e che cosa ricava dalla definizione di banca come «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria»?

Risposta ideale. L'art. 1 è fuori dai Titoli perché serve all'intero decreto, e aprire con le definizioni è una scelta di tecnica legislativa estranea alla tradizione italiana: evita equivoci e

fornisce il punto di aggancio con le nozioni comuni del diritto europeo. Il comma 1 definisce le espressioni ricorrenti, dalle autorità creditizie alla banca; il comma 2 le nozioni su cui regge l'accesso al mercato: banca italiana, con sede legale in Italia; banca dell'Unione europea, con sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato, requisito congiunto per evitare elusioni; banca di Stato terzo; succursale; attività ammesse al mutuo riconoscimento. La definizione di banca come «impresa autorizzata», alla lett. b) del comma 1, ha tre conseguenze. La banca è impresa e non servizio pubblico: la legge chiude un dibattito antico e fa dell'autonomia imprenditoriale la regola. È impresa autorizzata, e l'autorizzazione ha efficacia costitutiva, perché senza di essa non esiste giuridicamente una banca, tanto che l'esercizio abusivo è reato ai sensi dell'art. 131. E non ha oggetto sociale libero, perché la qualifica dipende dall'esercizio effettivo dell'attività bancaria: le altre attività consentite dall'art. 10, comma 3, si aggiungono ad essa e non la sostituiscono. Se la banca è impresa, resta da vedere in che cosa il suo statuto è derogato.

1.11. D11 — La banca come impresa: in che cosa è derogato lo statuto dell'imprenditore

Domanda. Lei ha detto che la banca è impresa e che vale lo statuto dell'imprenditore commerciale. Mi indichi allora in che cosa quello statuto è derogato.

Risposta ideale. Il carattere d'impresa è la regola, e le deroghe sono tutte espresse; riguardano tre momenti della vita della banca. All'ingresso, l'impresa ordinaria si costituisce e si iscrive, mentre la banca deve prima ottenere l'autorizzazione, e l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se l'autorizzazione non consta: è la traduzione della riserva dell'art. 10, comma 2, e spiega perché l'esercizio abusivo sia reato. Nella vita dell'impresa l'autonomia statutaria è compressa: la forma è solo s.p.a. o cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede legale e direzione generale in Italia, art. 14, comma 1, lett. a) e a-bis); gli assetti proprietari sono soggetti all'art. 19, gli esponenti all'art. 26, e le modifiche statutarie sono accertate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56. All'uscita la banca non fallisce: l'art. 80, comma 6, la sottrae alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, che è disposta con decreto del Ministro dell'economia su proposta della Banca d'Italia, comma 1. La ratio è che il dissesto di una banca non colpisce solo i creditori, ma il risparmio tutelato dall'art. 47 Cost. e la stabilità dell'art. 5. Le deroghe non smentiscono la qualificazione imprenditoriale, la presuppongono: se la banca non fosse impresa, non servirebbe derogare espressamente allo statuto dell'imprenditore.

1.12. D12 — La riserva dell'attività bancaria, la raccolta tra il pubblico e la riserva di denominazione

Domanda. Mi illustri la riserva dell'attività bancaria: che cosa è la raccolta tra il pubblico e come è presidiata la riserva? La riserva di denominazione è la stessa cosa?

Risposta ideale. La riserva è nell'art. 10: il comma 1 definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, il comma 2 la riserva alle banche. Si regge sull'art. 11, che definisce la raccolta come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o in altra forma, e la vieta ai non bancari quando è tra il pubblico. Il divieto ha eccezioni dosate. Non è raccolta tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica o inserita in conti di pagamento usati solo per servizi di pagamento, commi 2-bis e 2-ter; il CICR individua le categorie, per rapporti societari o di lavoro, presso cui non lo è, comma 3; il comma 4 esclude fra gli altri le società che raccolgono con obbligazioni secondo il codice civile, ma il comma 5 vieta comunque la raccolta a vista. La riserva è presidiata penalmente: l'art. 130 punisce la raccolta abusiva, l'art. 131 la raccolta abusiva unita all'esercizio del credito, cioè l'attività bancaria intera, e l'art. 131-bis l'abusiva emissione di moneta elettronica. La riserva di denominazione dell'art. 133 è diversa: riguarda il nome, vieta ai non bancari parole come «banca», «banco», «credito» e «risparmio» ed è presidiata da sanzione amministrativa. La prima protegge la sostanza, il risparmio che non finisca a soggetti non vigilati; la seconda l'affidamento che il nome genera.

1.13. D13 — Il TUB e il Testo unico della finanza

Domanda. Il TUB non è l'unico testo unico del sistema finanziario. Come si rapporta con il Testo unico della finanza, e dove lo si vede dal testo del TUB?

Risposta ideale. Il TUB descrive il soggetto e l'attività bancaria, il TUF abilita ai servizi di investimento e disciplina i mercati: il confine si legge dall'interno del TUB. La cerniera è l'art. 10, comma 3: la banca esercita, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna», e sono salve le riserve di attività previste dalla legge; per i servizi di investimento quella disciplina propria è nel TUF. I rinvii sono verificabili senza uscire dal TUB. L'art. 1, comma 2, lett. c), definisce la banca di Stato terzo richiamando l'art. 14 e l'art. 20-bis.1 del decreto 58/1998; l'art. 16, comma 4, fa salvo l'art. 29-ter del TUF; l'art. 106, comma 2, lett. b), consente agli intermediari finanziari di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF. Anche le autorità si coordinano senza confondersi: la CONSOB è definita dall'art. 1, comma 1, lett. d), ma non è fra le autorità creditizie, e l'art. 7, comma 5, impone a Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS di collaborare senza potersi opporre il segreto d'ufficio, mentre gli artt. 15 e 16 prevedono che la Banca d'Italia informi la CONSOB quando è previsto l'esercizio di intermediazione mobiliare. Il TUB presuppone dunque un riparto di competenze e ne organizza il coordinamento, ma il criterio va cercato nell'altro testo unico.